

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

**nr. 234.272 van 25 maart 2016
in de zaak A. 218.560/XII-8096**

In zake: de BVBA 3M BELGIUM
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaten Anthony Poppe en Marie Vastmans
kantoor houdend te 1160 Brussel
Tedescolaan 7
bij wie woonplaats wordt gekozen
eveneens bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Anthony Bochon

tegen:

de VLAAMSE GEMEENSCHAP
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaten Jens Debièvre, Lore Derdeyn en Mehdy Abbas Khayli
kantoor houdend te 1000 Brussel
Havenlaan 86c b113
bij wie woonplaats wordt gekozen

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, elektronisch ingesteld op 26 februari 2016, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van:

“[d]e beslissing van de Secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin van de Vlaamse Overheid van 12 februari 2016 houdende niet-plaatsing van de raamovereenkomst door middel van een open offertaanvraag voor het ter beschikking stellen van een applicatie voor het beheer van het elektronisch toezicht alsook de levering van uitrustingen voor het elektronisch toezicht van justitiabelen voor de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap (bestek nr. WVG/DEP/JH/VCET/1/1) (eerste bestreden beslissing);

[d]e beslissing van de Secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin van de Vlaamse Overheid van 12 februari 2016 tot het overdoen van de procedure tot gunning van de raamovereenkomst voor het ter beschikking stellen van een applicatie voor het beheer van het elektronisch toezicht alsook de levering van uitrustingen voor het elektronisch toezicht van justitiabelen voor de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap door middel van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (tweede bestreden beslissing)”.

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 17 maart 2016, om 14.30 uur.

Staatsraad Pierre Barra heeft verslag uitgebracht.

Advocaten Anthony Poppe en Anthony Bochon, die verschijnen voor de verzoekende partij, en advocaten Jens Debièvre en Lore Derdeyn, die verschijnen voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur Ann Eylenbosch heeft een met dit arrest wat de tweede bestreden beslissing betreft eensluidend en wat de eerste bestreden beslissing betreft andersluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. De Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap organiseren een samengevoegde overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp “Raamovereenkomst d.m.v. een open offerteaanvraag voor het ter beschikking stellen van een applicatie voor het beheer van het

elektronisch toezicht alsook de levering van uitrustingen voor het elektronisch toezicht van justitiabelen”.

De Vlaamse Gemeenschap treedt op als aanbestedende overheid.

De opdracht wordt aangekondigd in het Bulletin der Aanbestedingen van 6 februari 2015 en in het Supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie van 11 februari 2015.

De opdracht wordt gegund volgens de procedure van de open offerteaanvraag, met als modaliteit de raamovereenkomst.

Op de opdracht is het bestek WVG/DEP/JH/VCET/1 van toepassing.

Het bestek omschrijft het voorwerp en de aard van de opdracht als volgt:

“De raamovereenkomst betreft het ter beschikking stellen en hosten, in de vorm van huur zonder aankoopoptie, van een applicatie voor het beheer van het elektronisch toezicht, de levering van uitrustingen en toebehoren voor het elektronisch toezicht van justitiabelen, het verlenen van support aan de medewerkers van de dienst voor elektronisch toezicht, het ter beschikking stellen van de handboeken en het verstrekken van opleiding.

Het betreft een overheidsopdracht voor leveringen.

Deze opdracht bevat één perceel en behelst volgende materialen en diensten (de ook B. Technische voorschriften):

Levering en onderhoud van apparatuur voor het elektronisch toezicht van justitiabelen. Er worden 7 types onderscheiden (zie ook B. Technische voorschriften), met name:

- type 1: oplossing voor het elektronisch toezicht van een justitiabele in de eigen woning aan de hand van een TPI en een eenheid voor toezicht (RF), daaronder begrepen de mogelijke signaalherhalers(s);
- type 2: oplossing voor het elektronisch toezicht van een justitiabele op alle plaatsen aan de hand van een eenheid voor follow-up en een eenheid voor toezicht (RF+GPS+LBS), daaronder begrepen de mogelijke signaalherhalers(s);

- type 3: oplossing voor het elektronisch toezicht van een justitiabele in de eigen woning via stemherkenning;
- type 4: oplossing van dubbele controle waarbij de types 1 en 3 worden gecombineerd (zie hierboven);
- type 5: oplossing van dubbele controle waarbij de types 2 en 3 worden gecombineerd (zie hierboven);
- type 6: oplossing voor het geolokaliseren van een slachtoffer en voornoemd slachtoffer ervan op te hoogte te brengen dat de onder elektronisch toezicht geplaatste justitiabele aan het naderen is;
- type 7: ‘pack’ bestaande uit een installatiekit en een eenheid voor mobiele controle.

Daarnaast dient de leverancier te voorzien in:

- de levering en onderhoud van een software en bijhorende hardware met het oog op het beheer van personen onder elektronisch toezicht (ABET);
- de ontwikkeling en het onderhoud van een interconnectie met de bestaande informaticatoepassing van het beheer van het elektronisch toezicht Siset;
- de opleiding van de medewerkers van de dienst voor elektronisch toezicht en het ter beschikking stellen van de bijhorende documentatie;
- het verlenen van technische support aan de dienst voor elektronisch toezicht. [...]

De inschrijvers worden volgens het bestek getoetst aan de hiernavolgende selectiecriteria:

“12.1.2. Selectiecriteria inzake de financiële draagkracht van de inschrijver [...]

12.1.3. Selectiecriteria met betrekking tot de technische bekwaamheid van de inschrijver

Eerste criterium inzake de technische bekwaamheid van de inschrijver

De inschrijver moet over de volgende referenties aan uitgevoerde leveringen en diensten beschikken die werden uitgevoerd tijdens de laatste drie jaren. [...]

Als de inschrijver, wat dit criterium betreft, zich beroept op de draagkracht van onderaannemers, is het zijn taak om de aanbestedende overheid te bewijzen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van voornoemde onderaannemers om hem dergelijke middelen ter beschikking te stellen. In voorkomend geval moet de inschrijver in zijn offerte vermelden welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt (zie punt 15.3) [...]

12.1.4. Selectiecriteria met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens [...]"

De offertes moeten elektronisch worden ingediend.

De gunningscriteria zijn: de technische waarde op 60% van de punten en de prijs op 40%.

3.2. Blijkens het proces-verbaal van opening van de offertes van 4 mei 2015 zijn er vier offertes ingediend, namelijk door de bvba 3M Belgium, dit is de verzoekende partij, Buddi Ltd, SuperCom Ltd en het consortium van de nv G4S Secure Solutions, de nv G4S Secure Monitoring en G4S Monitoring Technologies Ltd.

3.3. De beoordeling van de offertes is opgenomen in het zogenaamde “niet-plaatsingsverslag” van 28 januari 2015 (hierna: het verslag). Hierin worden de inschrijvers de bvba 3M Belgium, Buddi Ltd en het consortium van de nv G4S Secure Solutions, de nv G4S Secure Monitoring en G4S Monitoring Technologies Ltd, geweerd omdat zij niet voldoen aan de eisen inzake het toegangsrecht of de kwalitatieve selectiecriteria. SuperCom Ltd voldoet volgens dit verslag wel aan die eisen en heeft een formeel regelmatige offerte ingediend doch haar offerte wordt geweerd wegens materiële onregelmatigheid, namelijk de offerte is niet conform de technische besteksvereisten. In het verslag wordt als conclusie voorgesteld de opdracht niet te gunnen.

De verzoekende partij voldoet volgens het verslag niet aan de kwalitatieve selectievereisten terwijl SuperCom Ltd wel hieraan voldoet om de volgende redenen:

“B. Onderzoek en beoordeling offertes

1 Selectie [...]

1.2. Verbintenis onderaannemers

Aangezien 3M en SuperCom beroep doen op de draagkracht van onderaannemers om te voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie, werd eerst onderzocht of er een verbintenis bestond van de betreffende onderaannemers en of deze ondertekend werd door natuurlijke personen die bevoegd waren de betrokken vennootschappen te verbinden.

Hieromtrent werd via e-mail aanvullende informatie gevraagd aan 3M (stukken die de bevoegdheid van [T.M.] om 3M Electronic Monitoring Ltd. te verbinden aantonen) en aan SuperCom (stukken die de bevoegdheid van [G.U.] om Satellite Tracking of People (STOP) LLC te verbinden aantonen, alsook stukken die de bevoegdheid van [G.D.] om NAOS-Services SPRL te verbinden aantonen). Deze werd door 3M op 13 augustus 2015 (verklaring van de advocaten van 3M Electronic Monitoring Ltd) en door SuperCom op 16 augustus 2015 (gecertificeerde verklaring van het enige lid van Satellite Tracking of People (STOP) LLC en statuten van NAOS-Services SPRL) via e-mail bezorgd.

Na analyse van de offertes en de bezorgde informatie blijkt het volgende:

- SuperCom doet beroep op de draagkracht van Satellite Tracking of People LLC en op die van Naos-Services Sprl. Voor deze twee onderaannemers werd een verbintenis bijgevoegd, die ondertekend werd door natuurlijke personen die bevoegd waren de betrokken vennootschappen te verbinden
- 3M doet beroep op de draagkracht van 3M Electronic Monitoring Ltd. en op die van SAIT nv. De verbintenis van SAIT nv is ondertekend door een natuurlijk persoon die bevoegd is de vennootschap te verbinden. Het document dat de verbintenis van 3M Electronic Monitoring Ltd moet aantonen, werd echter niet ondertekend door een persoon die bevoegd was om de vennootschap op die wijze te verbinden. Bij de verdere beoordeling van de offerte van 3M kan er dan ook geen rekening gehouden worden met draagkracht van 3M Electronic Monitoring Ltd. [...]

1.4 Kwalitatieve selectiecriteria [...]

In verband met het eerste selectie criterium inzake de technische bekwaamheid van de inschrijver werd via e-mail aanvullende informatie (attesten voor referenties van onderaannemers) gevraagd aan SuperCom. Deze werd op 16 augustus 2015 via e-mail bezorgd.

Na analyse van de offertes en de bezorgde informatie blijkt het volgende:

- G4S en SuperCom voldoen aan het eerste selectie criterium met betrekking tot de technische bekwaamheid;
- 3M voldoet niet aan het eerste selectie criterium inzake de technische bekwaamheid. Alle ingediende referenties hebben immers betrekking op leveringen en diensten van 3M Electronic Monitoring Ltd. Aangezien echter werd vastgesteld dat er geen geldige verbintenis is van 3M Electronic Monitoring Ltd. (zie titel 1.2), kan met deze referenties geen rekening worden gehouden.”

3.4. Bij besluit van 12 februari 2016 beslist de secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap om de redenen uiteengezet in het verslag de opdracht niet te plaatsen.

Dit is de eerste bestreden beslissing.

Bij afzonderlijk besluit van 12 februari 2016 beslist dezelfde secretaris-generaal de plaatsing van de raamovereenkomst over te doen volgens de gunningsprocedure van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de volgende motivering:

“Overwegende dat de gemeenschappen de offertes voor de overheidsopdracht met als nummer WVG/DEP/JH/VCET/1/1 hebben bestudeerd en hebben vastgesteld dat enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes werden ingediend;

Overwegende dat het bijgevolg wenselijk is een overheidsopdracht uit te schrijven onder de vorm van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, op basis van artikel 26, §1, 1°, e) van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, volgens hetwelk het mogelijk is dergelijke procedure aan te wenden wanneer ‘enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes werden ingediend naar aanleiding van een open of beperkte procedure of concurrentiedialoog, mits de aanbestedende overheid alle inschrijvers raadpleegt die aan de eisen inzake kwalitatieve selectie beantwoorden en bij de eerste procedure een formeel regelmatige offerte hebben ingediend, en de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd’;

Overwegende dat aan al deze voorwaarden is voldaan”.

Dit is de tweede bestreden beslissing.

Hierop start de verwerende partij onderhandelingen met SuperCom Ltd die als enige inschrijver werd geselecteerd en een formeel regelmatige offerte indiende bij de vorige gunningsprocedure.

IV. Schorsingsvoorwaarden

4.1. Krachtens artikel 17, §§ 1 en 4, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende

noodzakelijkheid slechts worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat minstens één ernstig middel wordt aangevoerd dat de nietigverklaring van de akte of het reglement *prima facie* kan verantwoorden en dat een uiterst dringende noodzakelijkheid voorhanden is die onverenigbaar is met de behandelingstermijn van de gewone vordering tot schorsing.

4.2. Te dezen is evenwel ook de wet van 17 juni 2013 ‘betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten’ van toepassing.

Krachtens artikel 15, eerste lid, van die wet kan de uitvoering worden geschorst van de thans bestreden beslissingen in aanwezigheid van een ernstig middel of een klaarblijkelijke onwettigheid.

Overeenkomstig artikel 15, tweede lid, echter wordt de vordering tot schorsing voor de Raad van State uitsluitend ingesteld volgens een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Er dient te dezen dan ook enkel nog te worden onderzocht of minstens één ernstig middel wordt aangevoerd, dan wel een klaarblijkelijke onwettigheid aanwezig is, die de nietigverklaring van de bestreden beslissingen kunnen verantwoorden.

V. Onderzoek van het eerste en het derde middel

Standpunt van de partijen

5.1. De verzoekende partij voert in haar eerste middel de schending aan van het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel, vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 5 van de wet van 15 juni 2006 ‘overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten’, van artikel 48, derde lid van de richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 ‘betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten’ “alleen of in samenhang gelezen” met artikel 74 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011
‡CFDQIEHBE-BCEEHAV‡

‘plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren’ (hierna het koninklijk besluit Plaatsing) en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel.

Zij betoogt dat de eerste bestreden beslissing deze bepalingen en beginselen schendt:

“Doordat besloten werd dat verzoekende partij geen bewijs voorlegde van een geldige verbintenis met de onderneming 3M EM louter omdat de natuurlijke persoon die de overeenkomst heeft ondertekend voor 3M EM niet over de nodige vertegenwoordigingsbevoegdheid zou beschikken;
Doordat een onderzoek gevoerd werd van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van een orgaan van een onderaannemer;
Doordat het bestek geen plicht tot bewijs van de vertegenwoordigingsbevoegdheid oplegde van de natuurlijke persoon die een andere entiteit vertegenwoordigt op wiens draagkracht een beroep wordt gedaan voor de uitvoering van de opdracht;
Doordat opgelegd werd om een verbintenis voor te leggen om te bewijzen dat verzoekende partij een beroep kon doen op de draagkracht van 3M EM voor de uitvoering van de opdracht;
Doordat uit verschillende elementen van het offertedossier blijkt dat verzoekende partij een aanspraak zal kunnen doen op de draagkracht van 3M EM voor de uitvoering van de opdracht;
Doordat de overheid niet heeft gevraagd om in geval van twijfel aanvullende inlichtingen neer te leggen;
Doordat aan de onderneming SUPERCOM ltd zelfs de mogelijkheid werd gegeven om haar offerte aan te vullen met de referenties zelf van haar onderaannemer;
Doordat het Belgisch recht van toepassing werd verklaard op de verbintenis tussen 3M EM en verzoekende partij;
Terwijl overeenkomstig artikel 48, lid 3, van de Overheidsopdrachtenrichtlijn 2004/18/EG en artikel 74 van het K.B. Plaatsing dd. 15 juli 2011 het bewijs dat men zich kan beroepen op de draagkracht van andere entiteiten voor de uitvoering van de opdracht soepel moet kunnen geleverd worden;
Terwijl de aanbestedende overheid zelfs niet kan eisen dat een verbintenis wordt voorgelegd;
Terwijl er naar gestreefd moet worden een zo ruim mogelijke mededinging mogelijk te maken in het kader van een overheidsopdracht;
Terwijl een administratieve rechtshandeling moet gesteund zijn op feiten die draagkrachtig zijn en hun grondslag in het administratief dossier vinden;
Terwijl de overheid geen maatregelen mag nemen die de mededinging kunnen beperken;

Terwijl elke administratieve handeling gesteund moet zijn op pertinente en deugdelijke motieven;
Terwijl elke administratieve rechtshandeling moet steunen op een zorgvuldig onderzoek van het dossier;
Terwijl geen beslissing kennelijk onredelijk mag zijn;
Zodat de in het middel aangehaalde beginselen geschonden worden.”

In een tweede middelonderdeel betoogt de verzoekende partij onder meer dat de bestreden beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel schendt doordat de verwerende partij niet van de mogelijkheid heeft gebruik gemaakt “om, indien zij van oordeel zou zijn dat er twijfel bestaat over de verbintenis van 3M EM, om aan verzoekende partij te vragen de nodige verduidelijkingen te doen overeenkomstig artikel 59 van het K.B. Plaatsing” en zij vervolgt:

“42. In het kader van de mogelijkheid tot onderzoek werd het volgende opgemerkt in het gunningsverslag bij de eerste bestreden beslissing:

‘In verband met het eerste selectie criterium inzake de technische bekwaamheid van de inschrijver werd via e-mail aanvullende informatie (attesten van referenties van onderaannemer) gevraagd aan SuperCom. Deze werd op 16 augustus 2015 via e-mail bezorgd.’ [...]

Aan SuperCom werd dus blijkbaar zelfs toegelaten om de referenties zelf van haar onderaannemers nog toe te voegen die noodzakelijk waren om te voldoen aan het eerste selectie criterium.

A fortiori had in het licht van het zorgvuldigheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel bijgevolg moeten onderzocht worden of verzoekende partij zich daadwerkelijk kon beroepen op de referenties van haar onderaannemer en zusteronderneming 3M EM in het kader van dit selectie criterium.”

5.2. De verzoekende partij voert in haar derde middel aan dat uit het ernstig bevinden van het eerste middel voortvloeit dat niet vaststaat dat haar offerte niet beantwoordt aan de kwalitatieve selectiecriteria en aldus artikel 26, § 1, van de voormelde wet van 15 juni 2006 is geschonden; dit zou inhouden dat de tweede bestreden beslissing evenzeer onwettig is.

6.1. De verwerende partij merkt op dat het eerste middel onontvankelijk is in zoverre het is gericht tegen de tweede bestreden beslissing; de

verzoekende partij geeft zelf aan dat het middel is gericht tegen de eerste bestreden beslissing.

Voorts merkt de verwerende partij op dat zij wel degelijk verduidelijkingen heeft gevraagd aan de verzoekende partij al was zij daartoe niet verplicht. Zij vervolgt:

“2.18. Daar waar Verwerende partij tot slot wordt verweten dat zij ook SuperCom de mogelijkheid heeft gegeven bepaalde elementen van de offerte te verduidelijken, dient opgemerkt dat dit kadert in het beginsel van gelijkheid der inschrijvers. Ook Verzoekende partij heeft de mogelijkheid gekregen om bepaalde elementen te verduidelijken (stuk 16a en stuk 16c). Bovendien zijn beide situaties niet vergelijkbaar: het toelichten of vervolledigen van reeds aangereikte informatie is een andere zaak dan het moeten aanleveren van het bewijs van bevoegdheid, zoals gevraagd aan Verzoekende partij. SuperCom heeft initieel wel degelijk referenties overgemaakt. Het bijkomend opvragen van bepaalde informatie in het kader van deze referenties schendt in deze geenszins het gelijkheids- of redelijkheidsbeginsel. Dit wordt ook niet aangetoond door Verzoekende partij. Verwerende partij heeft dan ook enkel stukken opgevraagd met objectieve en niet voor verandering vatbare gegevens die op ieder ogenblik kunnen worden gecontroleerd en waarvan het vaststaand en zeker karakter van deze gegevens bestaat vóór het uiterlijke tijdstip van indiening van de offertes.”

6.2. De verwerende partij voert aan dat het derde middel onduidelijk is geformuleerd en dat het niet ernstig is omdat de verzoekende partij niet zou aantonen dat zij in elk geval diende te worden geselecteerd en dat haar offerte zowel formeel als materieel regelmatig is.

Beoordeling

7. De verwerende partij heeft het document met de verbintenis van 3M Electronic Monitoring, waaruit met toepassing van artikel 74 van het koninklijk besluit Plaatsing zou blijken dat deze onderneming de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen aan de verzoekende partij ter beschikking stelt, niet aanvaard om reden dat volgens haar dit document niet was ondertekend door een persoon die bevoegd was om de onderneming op die wijze te verbinden.

Een dergelijke verbintenis ten voordele van de inschrijver SuperCom Ltd gegeven door de onderneming Satellite Tracking of People LLC Inc. USA (hierna STOP) is door de verwerende partij wel aanvaard.

Het is passend deze verbintenis van STOP aan een nader onderzoek te onderwerpen, tevens in het licht van het debat ter terechtzitting waar de verzoekende partij de rechtsgeldigheid van deze verbintenis in vraag stelt.

In eerste instantie voegt SuperCom Ltd bij haar offerte van 3 mei 2015 een verbintenis waarbij STOP haar middelen ter beschikking van de verzoekende partij stelt voor wat betreft ITM (Individueel Technische Materiaal) type 2 en type 7 van de opdracht.

Alsdan vraagt de verwerende partij bij e-mailbericht van 28 juli 2015 “aanvullende informatie” aan SuperCom Ltd; hierbij gaat het om tal van zaken zoals onder meer de statuten van SuperCom Ltd, de ondertekeningsbevoegdheid bij de offerte van SuperCom Ltd en de toestand van STOP inzake de uitsluitingscriteria. In het kader van het eerste criterium bij de selectiecriteria technische bekwaamheid vraagt de verwerende partij voorts aan SuperCom Ltd referenties inzake ITM type 1 omdat de bij haar offerte gevoegde referenties werden afgeleverd door STOP terwijl de voormelde verbintenis van die onderaannemer dit type niet omvat.

Bij e-mailbericht van 16 augustus 2015 (stuk 15e administratief dossier) antwoordt SuperCom Ltd op dit laatste als volgt:

“Voor het eerste criterium inzake de technische bekwaamheid vraagt het bestek de inschrijvers om referenties met betrekking tot de *‘mise à disposition de MTI (au moins similaires aux types 1 ou 2 décrits au point 1) et d’une AGSE permettant la surveillance électronique de justiciables’* in te dienen.

Voor dit criterium beroept SuperCom zich op de bekwaamheid van een andere entiteit, STOP LLC, overeenkomstig artikel 74 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011. STOP LLC heeft zich ertoe verbonden om aan SuperCom ITM van type 2 ter beschikking stellen. Ons inziens wordt hiermee voldaan aan de vereiste om referenties in te dienen met betrekking tot de ter beschikking stelling van ITM *‘au moins similaires aux type 1 ou 2’*.

Wij stellen echter vast dat de Franstalige en de Nederlandstalige versie van het bestek elkaar op dit punt tegenspreken, omdat in de Nederlandstalige versie sprake is van ITM ‘gelijkaardig aan type 1 en 2’. Ongeacht de wijze waarop u deze tegenstrijdigheid zal oplossen, bezorgen wij u een nieuwe verbintenis van STOP LLC die betrekking heeft op de terbeschikkingstelling van ITM type 1 en 2 [...].

Voor alle duidelijkheid beroept SuperCom zich dus, voor wat betreft het eerste criterium inzake de technische bekwaamheid, op de bekwaamheid van een derde en dient zij hiervoor referenties van STOP in met betrekking tot type 1 en 2. SuperCom legt aldus een verbintenis van STOP voor om zijn technische bekwaamheid ter beschikking te stellen van SuperCom met betrekking tot ITMs van type 1 en type 2.”

SuperCom Ltd voegt aldus bij haar e-mailbericht een nieuwe verbintenis van haar onderaannemer STOP, gedateerd op 7 augustus 2015, waarbij die laatste er zich toe verbindt “zijn technische kundigheid” inzake type 1, type 2 en 7 toestellen “ter beschikking te stellen van SuperCom Ltd met als doel de uitvoering van de raamovereenkomst”. Blijkens het e-mailbericht van SuperCom Ltd beroept zij zich uitdrukkelijk op deze nieuwe verbintenis.

De verwerende partij lijkt aldus aan SuperCom Ltd de gelegenheid te hebben gegeven om haar offerte aan te vullen met een nieuwe verbintenis die, zo lijkt, ruimer is, namelijk met ITM type 1 uitgebreid, dan deze die initieel bij de offerte was gevoegd. Op het eerste gezicht lijkt de aanbestedende overheid dan ook in het geval van SuperCom Ltd een na opening van de offertes aangepaste of bijkomende verbintenis van haar onderaannemer te hebben toegelaten terwijl zij wat de offerte van de verzoekende partij betreft de referenties van diens onderaannemer, 3M Electronic Monitoring, weigerde omdat deze onderaannemer geen rechtsgeldige verbintenis had voorgelegd. Aldus lijkt de verwerende partij hier te zijn tekort gekomen aan het door de verzoekende partij ingeroepen gelijkheidsbeginsel, nog ongeacht de vragen in hoeverre het op zich al zou zijn toegelaten om een offerte na indiening te wijzigen door de verbintenis van de onderaannemer te vervangen en uit te breiden dan wel welk gevolg er diende te worden gegeven aan de op het eerste gezicht vastgestelde bestekstegenspraak.

Deze vaststellingen volstaan om de beide bestreden beslissingen te schorsen in hun tenuitvoerlegging. De aangenomen schending van het gelijkheidsbeginsel verantwoordt dat de verzoekende partij belang heeft bij de

schorsing van de tenuitvoerlegging van de eerste bestreden beslissing. De verwerende partij wordt ertoe aangezet om een nieuwe beslissing te nemen waarbij, zo lijkt, alle aspecten van het toegangsrecht en de selectie van de inschrijvers en van de regelmatigheid van de offertes aan bod zullen moeten komen. Aangezien voorts de draagwijdte van het ernstig bevonden eerste middel zowel de formele regelmatigheid van de offerte van SuperCom Ltd als de selectie van haarzelf in vraag stelt, dient ook de tweede bestreden beslissing om die reden alleen reeds, aangezien hieruit volgt dat niet meer zeker is of wel aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 26, § 1, 1°, e), van de voormelde wet van 15 juni 2006 werd voldaan, in haar tenuitvoerlegging te worden geschorst.

Het is passend de kosten in beraad te houden.

BESLISSING

De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de beslissing van de secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin van de Vlaamse Gemeenschap van 12 februari 2016 houdende de niet-plaatsing van de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp “Raamovereenkomst door middel van een open offerteaanvraag voor het ter beschikking stellen van een applicatie voor het beheer van het elektronisch toezicht alsook de levering van uitrustingen voor het elektronisch toezicht van justitiabelen” en van de beslissing van de secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin van de Vlaamse Gemeenschap van 12 februari 2016 tot het overdoen van de procedure tot gunning van deze overheidsopdracht door middel van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van 25 maart 2016,
door de Raad van State, XIIe kamer, samengesteld uit:

Pierre Barra,	staatsraad,
	waarnemend voorzitter,
bijgestaan door	
Silja Doms,	griffier.

De griffier

De voorzitter

Silja Doms

Pierre Barra